

1500911-52.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... do Código de Processo Penal. 2.2 - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO TJ-DF: Embargos

Infringentes Criminais. EIR 20120111829890 (TJ-DF). Ementa: PENAL EMBARGOS

INFRINGENTES E DE NULIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. FALTA DE PROVAS DA MERCANCIA. RECURSO PROVIDO. I. A apreensão de pequena quantidade de droga, bem como a ausência de investigações em curso, a demonstrar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500911-52.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2158280/2021

- 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 112/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO LUIZ MARTINS DE SIQUEIRA JUNIOR

Contr. nº 2021/000631

Aos 23 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu ANTONIO LUIZ MARTINS DE SIQUEIRA JÚNIOR. Presente o(a) defensor(a)

Dr(a). Janaína Aparecida Martins de Almeida, a qual foi constituída nesta data, pelo acusado. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PC Márcio Luiz Teixeira de Camargo Brahun e PC Fabio Luis Gonçalves Hisdorf. Presente(s) a(s) testemunha(s) de defesa: SILVIANE TERESA SIQUEIRA DA SILVA e SIDNEI CARDOSO

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s) e réu, o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, pela defesa foi dito que dispensava oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusado(a).

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente as comuns (PC Márcio e PC Fabio), após as de defesa (Silviane e Sidnei) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ANTONIO LUIZ MARTINS DE SIQUEIRA JUNIOR, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 11 de junho de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Alameda Lavínia Galesi Furlan Falzoni, Bairro Cecap, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, tinha em depósito, 5,7g de Cannabis sativa L., distribuídos em 06 porções, e 5,6g de cocaína, distribuídos em 27 eppendorfs, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 112/115). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 08, foto a fl. 09/10 e laudo definitivo a fls. 105/107. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o policial Márcio relatou, na fase informativa (fls. 02), que diligências de forma velada na companhia do policial FÁBIO, em local tido como ponto de venda de drogas, oportunidade que visualizaram dois indivíduos em situação fática de traficância, sendo um deles de cor branca e outro de cor preta. Durante o período em que manteve o local em observação, visualizou o indivíduo de cor branca, efetuando uma venda de drogas para o condutor de um veículo Fox de cor verde, ou seja, se dirigiu a um canteiro próximo, dali retirou algo e entregou para o condutor do veículo, o qual por sua vez entregou o dinheiro para o indivíduo de cor preta. Optaram pela abordagem do indivíduo de cor branca, porém o indivíduo de cor preta, o qual estava um pouco distante desse indivíduo se evadiu do local, não sendo possível sua abordagem. O indivíduo abordado foi identificado como ANTONIO LUIZ MARTINS DE SIQUEIRA e consigo nada de irregular foi localizado. No canteiro onde o indivíduo foi visto, o depoente localizou dentro de um buraco, seis porções de maconha e vinte e sete eppendorfs contendo cocaína. Indagado a respeito dos fatos, o indiciado negou a posse ou propriedade da droga, atribuindo-a ao indivíduo que se evadiu". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que não conhecia o réu e que tinha certeza, pelo que visualizou, que o acusado estava vendendo drogas. O policial Fábio, por sua vez, ratificou o relatado por seu parceiro. A testemunha arrolada pela defesa Silviane nada acrescentou de relevante. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, o réu foi visto pelos policiais vendendo drogas, sendo apreendidos os entorpecentes no exato local em que ele os recolhia. Destarte, não havendo qualquer razão para não se dar a eles credibilidade entende-se devidamente demonstradas materialidade e autoria delitivas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu não ostenta antecedentes criminais (certidão a fls. 122/123).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM Juíza ANTONIO LUIZ MARTIN DE SIQUEIRA JUNIOR, já qualificado nos autos de processo crime que lhe move a JUSTIÇA PÚBLICA, vem respeitosamente perante a alta presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao r despacho, apresentar: MEMORIAIS FINAIS, 1. DA DENÚNCIA ANTONIO, foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pelos seguintes fatos narrados na denúncia: FATO : Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Alameda Lavínia Galesi Furlan Falzoni, Bairro Cecap, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, ANTONIO LUIZ MARTINS DE SIQUEIRA JUNIOR, qualificado a fl. 05, para fins de tráfico, tinha em depósito, 5,7g de Cannabis sativa L., distribuídos em 06

porções, e 5,6g de cocaína, distribuídos em 27 eppendorfs, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar¹. Segundo se apurou, policiais civis realizavam diligências no sobredito local, ocasião em que avistaram o denunciado em atitude típica de tráfico, pegando algo em um canteiro próximo e entregando a terceiros. Em razão disso, abordaram o denunciado, mas nada de ilícito localizaram em sua posse. Na sequência, realizaram buscas no referido canteiro e encontraram as drogas acima descritas, pertencentes ao denunciado e que se destinavam à mercancia ilícita.

2-DO DIREITO

2.1 DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

Partindo-se de uma visão constitucional do processo penal brasileiro, a sistemática de apuração da ocorrência de infração penal deve sempre levar em consideração os princípios da presunção de inocência ou de não culpabilidade (artigo 5º, LVII, CF/88), o princípio do favor rei ou do in dubio pro reo e o da paridade de armas, para que se possa chegar à conclusão de que o órgão acusador é o único responsável direto pela produção de provas, ou seja, o portador do ônus de provar cabalmente a existência da infração penal e quem foi o seu autor. Portanto, a premissa básica que o julgador deve ter ao examinar a sua causa é que o órgão acusador deve buscar a verdade real, produzindo provas judiciais claras e precisas de que houve uma infração penal e quem foi o seu autor ou partícipe, tudo com a observância das normas legais e constitucionais, sob pena de se reconhecer a dúvida, por menor que seja, em favor do réu, conforme preconiza o artigo 386, VII, do CPP. Feitas essas considerações, passa-se à defesa do acusado. O conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação no delito de tráfico de drogas que supostamente ocorreu, haja vista que o acusado nega veemente que estava na posse de qualquer substância entorpecente e com ele nada de ilícito fora encontrado. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação. Como se verifica do interrogatório da acusado, ele nega veementemente que jamais praticou o delito descrito na inicial acusatória. De mais a mais, o depoimento testemunhal utilizado pelo Ministério Público para tentar incriminar o acusado está em descompasso com o restante das provas, notadamente porque as únicas testemunhas que confirmam o fato narrado na inicial são os policiais que participaram da prisão, cujos depoimentos devem sempre ser visto com reserva, como bem é fundamentado pela Doutrina pátria: “[...] é de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. (...) Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento. Sobre a possibilidade de se arrolar somente policiais para depor, em lugar de efetivas testemunhas, isto é, aqueles que presenciaram algo diretamente vinculado ao fato, está a crítica de Espínola Filho: “Amanhã, a polícia é chamada ao lugar onde um crime foi ou está sendo cometido. Vão três ou quatro funcionários, encontram pessoas dando notícias detalhadas dos fatos, com minúcias e históricos completos; ouvem-nas, e delas abstraem inteiramente, daí a seguir; pois resolvem constituir-se em testemunhas, reportando à autoridade policial, na delegacia, o que lhes foi contado por toda aquela gente, que não foi incomodada, nem o nome lhe sendo tomado (Código de Processo Penal brasileiro anotado.v.3,p.90)” Deste modo, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, há de ser julgada improcedente a pretensão acusatória, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

2.2 - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Cumpramos ressaltar que o denunciado possui residência fixa, é primário, possui bons antecedentes e trabalho lícito. Cumpramos esclarecer ainda, que a denunciado não exerce comércio ilícito de entorpecentes conforme afirmado na denúncia. “[...] é de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. (...) Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento. Sobre a possibilidade de se arrolar somente policiais para depor, em lugar de efetivas testemunhas, isto é, aqueles que

presenciaram algo diretamente vinculado ao fato, está a crítica de Espínola Filho: "Amanhã, a polícia é chamada ao lugar onde um crime foi ou está sendo cometido. Vão três ou quatro funcionários, encontram pessoas dando notícias detalhadas dos fatos, com minúcias e históricos completos; ouvem-nas, e delas abstraem inteiramente, daí a seguir; pois resolvem constituir-se em testemunhas, reportando à autoridade policial, na delegacia, o que lhes foi contado por toda aquela gente, que não foi incomodada, nem o nome lhe sendo tomado (Código de Processo Penal brasileiro anotado.v.3,p.90)" Deste modo, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, há de ser julgada improcedente a pretensão acusatória, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

2.2 - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO TJ-DF: Embargos Infringentes Criminais. EIR 20120111829890 (TJ-DF). Ementa: PENAL EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. FALTA DE PROVAS DA MERCANCIA. RECURSO PROVIDO. I. A apreensão de pequena quantidade de droga, bem como a ausência de investigações em curso, a demonstrar suspeita de mercancia ilícita de entorpecentes, e a falta de abordagem de suposto adquirente são indicativos de que a droga era para consumo próprio. II. Ausente a prova inconteste do tráfico, correta a desclassificação da infração para uso próprio. Não é suficiente a probabilidade do cometimento do delito. A dúvida acerca da destinação das drogas apreendidas se revolve em favor do réu. III. Recurso provido. Verifica-se que nos autos não há nenhuma prova capaz de incriminar o denunciado de forma concreta e inequívoca ao delito em que é acusado, pelo contrário, existem apenas presunções. Como sabemos, no processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser indiscutível e cristalina. O denunciado não é nem nunca foi traficante, conforme aduzido na denúncia. Não há prova nos autos, de acordo com a análise dos depoimentos, do local do fato, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do denunciado, cheguem à certeza de que a prática do fato era realmente tráfico de drogas, razão pela qual, em caso de não absolvição, mostra-se necessária a desclassificação. O acusado é primário, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. No que diz respeito ao tráfico privilegiado, o legislador não estabeleceu um critério objetivo para determinar com será feita a diminuição, que pode ser de 1/6 a 2/3. Para NUCCI, o magistrado deve: Pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". É lógico que há de existir o cuidado de evitar o bis in idem, ou seja, levar em conta duas vezes a mesma circunstância. As causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual. Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição da pena (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base (a primeira etapa da aplicação da pena, conforme art. 68 do Código Penal). Presentes as atenuantes, a pena a ser cominada ao acusado deve ser a mínima legal.

3-DOS PEDIDOS Diante o exposto requer: I Que seja acolhida a tese de absolvição do denunciado, pela ausência de provas de que esta concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP e/ou Caso não seja este o entendimento, que seja absolvida por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. II - Caso entenda pela condenação do denunciado, o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis da denunciada (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que o denunciado preenche todos os requisitos. III - Em caso de condenação, a aplicação do art. 59 da Lei 11.343/06 c/c 283 do Código de Processo Penal, somado aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal), entendimento da prisão como ultima ratio, Lei

12.403/11 (medidas cautelares diversas da prisão), pelos efeitos negativos do cárcere, requisitos favoráveis do denunciado (primário, residência fixa, trabalho lícito), para que possa recorrer em liberdade. IV Por fim, caso vossa excelência decida pela condenação, que reconheça a circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a primariedade do agente, de forma a ser fixada a pena no mínimo legal. Termos em que Pede Deferimento.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

ANTONIO LUIZ MARTINS DE SIQUEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Alameda Lavínia Galesi Furlan Falzoni, Bairro Cecap, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, tinha em depósito, 5,7g de Cannabis sativa L., distribuídos em 06 porções, e 5,6g de cocaína, distribuídos em 27 eppendorfs, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais civis realizavam diligências no sobredito local, ocasião em que avistaram o acusado em atitude típica de tráfico, pegando algo em um canteiro próximo e entregando a terceiros. Em razão disso, abordaram Antonio, mas nada de ilícito localizaram em sua posse.

Narra, ainda, que na sequência, realizaram buscas no referido canteiro e encontraram as drogas acima descritas, pertencentes ao acusado e que se destinavam à mercancia ilícita.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 131). Defesa preliminar apresentada às fls. 135/136. Após, a denúncia foi recebida (fls. 141/142) e o réu foi citado (fls. 159).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e duas testemunhas da defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

Boletim de ocorrência de fls. 06/07;

Auto de exibição e apreensão de fl. 08;

Fotografias de fls. 09/10;

Laudo de constatação de fls. 13/17 e laudo de exame químico toxicológico de fls.

105/107, ambos com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 5), o réu permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), negou o crime. Disse que no dia dos fatos foi ao bar onde encontrou um colega, tomou um aperitivo. Foi abordado com o colega na porta do estabelecimento. O traficante que atuava naquele local fugiu naquele momento. Admitiu que, enquanto ficou ali, fez contato com o condutor de um automóvel, mas negou ter recebido ou entregado algo para ele. Disse que era um conhecido que parou ali para lhe oferecer um trabalho. Negou a propriedade das drogas apreendidas, dizendo que não acessou o canteiro onde estavam.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial civil Marcio Luiz Teixeira Barhun declarou que realizavam diligências de forma velada, em local já conhecido pela venda de drogas, quando

observaram dois indivíduos, um dos quais o réu, em atitude típica de tráfico. Disse que um veículo FOX se aproximou, seu condutor fez contato com o réu, entregou-lhe dinheiro. A seguir, o réu foi até um canteiro próximo, pegou algo, retornou e entregou ao condutor do automóvel. Na sequência, o dinheiro foi entregue ao rapaz que o acompanhava. Diante dessa atitude típica de tráfico de drogas, resolveram efetuar a abordagem. Conseguiram abordar o réu, que estava mais próximo, mas o rapaz para quem o réu entregou o dinheiro conseguiu fugir. Afirmou que, na revista pessoal, não encontraram nada de ilícito com o acusado. Porém, num buraco existente no canteiro de onde ele pegou algo, encontraram 6 porções de maconha e 27 porções de cocaína. Esclareceu que o acusado negou a propriedade da droga, dizendo que pertencia ao indivíduo que se evadiu quando da abordagem.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelo policial civil Fabio Luis Gonçalves Hilsdorf, ouvido na delegacia de polícia (fls. 04) e nesta data (gravação). Anoto que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que não há nos autos elementos dos quais se possa extrair que tinham intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição. O próprio réu disse que nada tinha contra eles.

Presume-se a lisura do agente público, pois investido no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

“Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta

típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO – j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais civis: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

As testemunhas arroladas pela defesa nada souberam dizer sobre os fatos, tendo apenas feito declarações favoráveis sobre o acusado e afirmado que ele era pessoa honesta e trabalhadora.

Vejamos:

Silviane Teresa Siqueira da Silva, ouvida em audiência (gravação), disse que é irmã do réu e que ele trabalha com ela em seu lava-rápido. No dia dos fatos, Antônio não foi trabalhar porque o serviço estava “fraco”. Desconhece seu envolvimento com tráfico de drogas.

Por fim, Sidnei Cardoso, igualmente ouvido em juízo (gravação) declarou que é vizinho do réu há muito tempo. Sabe que ele é trabalhador e que nunca iria se envolver com o comércio de drogas. Ele trabalhava no lava-rápido da irmã e, no dia dos fatos, só não foi trabalhar porque não tinha muito serviço.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu mantinha em depósito 06 porções de maconha e 27 porções de cocaína, as quais eram destinadas ao comércio e consumo de terceiros.

De fato, os policiais foram uníssomos em afirmar que, durante diligência velada, visualizaram o réu, na companhia de outro indivíduo, efetuando a venda de entorpecente para o condutor de um automóvel, em local que já era conhecido como ponto de tráfico de drogas. Também relataram de forma segura que as drogas apreendidas foram encontradas no exato local para o qual o réu se dirigiu, após fazer contato com o motorista, pegou um objeto e entregou ao condutor.

Não há dúvidas, portanto, de que as drogas lhe pertenciam e que eram destinadas ao comércio.

O destino mercantil se confirma não só diante da atitude típica de tráfico do réu, mas também diante do fato de as drogas estarem fracionadas e acondicionadas em porções individuais, como comumente são comercializadas (fotografia de fl. 09). Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática

de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 118/120 e certidão de fls. 122/123)

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistem atenuantes, agravantes ou causas de aumento.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de "envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com

organização criminosa" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ANTONIO LUIZ MARTINS DE SIQUEIRA JUNIOR a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos. Recebo o recurso interposto. Desde já sai a defesa intimada do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.